

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[기출][2020-3]공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

《【문제3】 A시 시장 乙은 甲이 A시에서 진행하고 있는 공사가 관련 법령을 위반하였다는 이유로 해당 공사를 중지하는 명령을 하였다. 甲은 그 명령 이후에 그 원인사유가 소멸하였음을 들어 乙에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였다. 그러나 乙은 그 원인사유가 소멸되지 않았다고 판단하여 甲의 신청에 대하여 아무런 응답을 하지않고 있다. 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시 시장 乙은 甲에 대한 공사중지명령 후 원인사유가 소멸하였다는 이유로 제기된 철회신청에 대하여 이를 받아들이지 않고 아무런 응답을 하지 않는 상황이다. 쟁점으로 <행정청이 철회신청에 대하여 응답하지 않은 것이 항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대해 설명한다.

II. 부작위의 성립 조건과 신청권의 법리

1. 행정소송법상 부작위의 성립 요건

(1) 부작위의 정의 및 범위

- "행정소송법 제2조 제1항 제2호"는 부작위를 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것으로 규정하고 있다.

(2) 부작위의 4대 성립 요건

- 행정소송법상 처분의 부작위가 성립하여 사법심사의 대상이 되기 위해서는 ① 당사자로부터 구체적인 처분의 신청이 존재할 것, ② 행정청에게 일정한 처분을 행하여야 할 공법상 작위 의무가 존재할 것, ③ 처분을 내리기에 상당한 기간이 경과하였을 것, ④ 행정청의 처분 등 어떠한 공권력 행사도 부존재할 것이라는 요건을 누적적으로 충족하여야 한다.

2. 법률상 신청권의 요구와 도출 근거

(1) 법률상 신청권의 필요성

- "대법원"은 행정소송법상 부작위가 성립하기 위해서는 단순히 당사자가 처분을 신청한 사실만으로는 부족하며, 그 당사자에게 행정청의 공권력 발령을 요구할 수 있는 구체적인 법률상 신청권이 귀속되어 있어야 한다고 일관되게 판단한다. 법률상 신청권이 없는 제3자 등의 단순한 민원이나 진정에 대하여 행정청이 무응답으로 일관하더라도 이는 소송법상 부작위가 될 수 없다.

(2) 신청권의 구체적 도출 경로

- 처분을 요구할 수 있는 신청권은 성문법상 명시적으로 규정되어 있는 경우뿐만 아니라, 개별 법령의 합리적인 해석을 통해 도출되거나 행정법의 일반 원칙에 근거한 조리(條理)를 통해서도 예외적·보충적으로 인정될 수 있다.

3. 공사중지명령의 해소와 조리상 철회신청권

(1) 침익적 처분의 지속 요건과 실체법적 한계

- 공사중지명령과 같은 제재적·침익적 행정처분은 처분 당시는 물론이고 그 집행 및 효력이 유지되는 전 과정에 걸쳐 실체법상 적법 사유가 계속해서 존재하여야 한다. 만약 처분 발령 이후 사정변경으로 인하여 제재의 원인이 되었던 법령 위반 등 비위 상태가 완전히 해소되었다면, 해당 명령을 유지할 실체법적 근거는 상실된다.

(2) 조리상 철회신청권에 관한 판례의 태도

- "대법원"은 공사중지명령을 받은 처분의 상대방은 그 명령의 원인사유가 완전히 해소되었다면 처분청에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청할 수 있는 조리상 신청권을 가진다고 판시하여 조리상 권리의 존재를 명백히 긍정하고 있다. 행정청의 철회의무에 대응하는 신청인의 적극적 권리를 인정함으로써 사법적 구제의 기틀을 제공한 것이다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 조리상 철회신청권 취득 여부

(1) 철회신청의 구체성 확보

- 사안에서 공사중지명령의 상대방인 甲은 단순한 행정지도나 질의를 한 것이 아니라, 명령 발령의 원인사유가 소멸하였음을 직접 주장하며 乙에게 구체적으로 공사중지명령의 철회를 구하는 처분을 신청하였다.

(2) 판례에 따른 조리상 신청권의 성립

- 공사중지명령의 원인사유가 해소되었다면 甲에게는 처분의 효력을 거두어 줄 것을 청구할 수 있는 조리상 신청권이 귀속된다. 따라서 甲은 乙에 대하여 정당한 사법적 응답을 요구할 수 있는 소송법상 적격 있는 신청권자에 해당한다.

2. 乙의 무응답 행위의 위법 부작위 해당성

(1) 乙의 법적 작위 의무의 존재

- 甲의 정당한 조리상 신청권 행사에 대응하여, A시 시장 乙은 실제로 원인사유가 소멸하였는지를 충실히 심사하여 처분을 철회해 주거나, 여전히 소멸하지 않았다고 판단될 경우 신청을 거부하는 처분을 대외적으로 발령해야 할 공법상 답변 의무(작위 의무)를 부담하게 된다.

(2) 상당 기간의 도과 및 무조치 상태의 완성

- 그럼에도 불구하고 乙은 甲의 신청에 대하여 상당한 기간이 경과하기까지 철회처분도, 거부처분도 행하지 않은 채 어떠한 의사표시도 없이 무응답으로 방치하고 있다. 이는 법적 의무를 해태한 무조치 상태이므로 행정소송법상 부작위 성립 요건을 완벽히 충족한다.

IV. 결론

- A시 시장 乙이 甲의 공사중지명령 철회신청에 대하여 무조치 및 무응답으로 일관한 행위는 "행정소송법 제2조 제1항 제2호" 소정의 위법한 부작위에 해당한다. "대법원 판례"에 따라 제재적 처분의 상대방에게는 사정변경에 따른 조리상 철회신청권이 인정되고, 행정청에게는 그에 알맞은 응답을 해 줄 작위 의무가 발생하기 때문이다. 결론적으로 乙의 방치는 사법적 권리구제의 대상이 되는 위법한 부작위가 되므로, 甲은 乙을 피고로 삼아 관할 행정법원에 부작위위법확인소송을 적법하게 제기하여 권리구제를 도모할 수 있다.